

1500556-92.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... para ela que iriam forjá-lo no tráfico, depois de uns dias foi abordado numa bicicletaria, ficaram com ele uma hora e meia para que ele assumisse o tráfico. Não tem filhos. Não usava droga perto do seu irmão. Foi preso em janeiro pois jogaram droga nele e o acusaram de tráfico. De outro lado, o acusado CAUÃ, em solo policial (fls. 10), afirmou que no momento que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500556-92.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104669/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 24351009 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2104669 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

CAUA VINICIUS BARROS DE SOUZA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD e Art. 35 "caput" do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

01/07/2022

Réu Preso

Em 01 de julho de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu CAUA VINICIUS BARROS DE SOUZA e DANIEL DOS SANTOS, bem como seus Defensores Técnicos, DRA. Daniela Nogueira OAB 390543/SP e DR. Fernando Nascimento dos Santos OAB 265834/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas DAVI DOS SANTOS e Daniel da Silva Martino (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de os acusados se entrevistarem reservadamente com os seus Defensores. De início, o representante do Ministério Público e a defensora do réu CAUÃ disseram que desistiam da oitiva da testemunha Eduardo Leopoldo Ambold, o que restou HOMOLOGADO pela MMa Juíza de Direito. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório dos réus. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas

iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. Os réus DANIEL DOS SANTOS e CAUÃ VINICIUS BARROS DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que: 1) no dia 16 de abril de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas; e 2) o dia 16 de abril de 2022, por volta das 16h30, na Rua Isaltino Campos Vieira, nº 297, e na Rua Ismênia Maria dos Santos, nº 236 - Tomás Guedes, nesta cidade e Comarca de Tatuí, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios, identidade de propósitos, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 3 porções de porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2,9 gramas, 13 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 12,50 gramas, e 9 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 11 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, os acusados se dedicavam ao tráfico ilícito, dividindo as tarefas na empreitada criminosa. Na prática delitiva, DANIEL fazia uso do imóvel em que residia, onde guardava e mantinha entorpecentes em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros. CAUÃ, por sua vez, associado com o comparsa, permanecia no local da abordagem, que ambos elegeram como "ponto", aguardando usuários para promover a venda oportuna, sendo que ia buscar drogas na residência de DANIEL conforme a demanda dos usuários. Guardas Municipais estavam em serviço quando receberam informação de um popular dando conta que CAUÃ (mencionando seu nome e a descrição das suas vestes) estava vendendo drogas no local dos fatos, que ele fazia uso de uma bicicleta e ia até a casa de seu comparsa DANIEL (também mencionado o nome) para buscar entorpecentes e promover a venda "para os viciados". De imediato, os Guardas Municipais se dirigiram para o local informado e, ao ganharem a Rua Isaltino Campos Vieira, avistaram CAUÃ, cujas vestes correspondias às relatadas na denúncia (camisa de time verde e boné vermelho), e deliberaram pela abordagem. Ao perceber a aproximação da viatura, CAUÃ dispensou drogas no chão e, em seguida, foi abordado. Em revista pessoal, com o denunciado, os Guardas encontraram a importância de R\$ 20,00 em espécie, valor angariado com a venda de drogas que ele promovia no local, associado a DANIEL. Em seguida, verificando o que o réu havia jogado no chão, os Guardas encontraram 3 porções de cocaína ("aricanduva"), individualmente embaladas e dispostas de modo a facilitar a venda. Na ocasião, indagado, CAUÃ admitiu a prática delitiva e disse que tinha "acabado de pegar as drogas" na residência de DANIEL. Dando continuidade às diligências, ao Guardas Civis se deslocaram até a casa de DANIEL, localizada na Rua Ismênia Maria dos Santos, nº 236. Lá chegando, eles encontraram seu irmão Davi e o cientificaram acerca da delação sobre a traficância. De imediato, Davi franqueou a entrada dos agentes públicos que, efetuando buscas, lograram encontrar na lavanderia, dentro de um "tanquinho", outras 13 porções de cocaína idênticas àquelas encontradas em poder de CAUÃ, além de 9 porções de "maconha", todas embaladas de forma individual, prontas para serem comercializadas. No armário, os Guardas ainda encontraram diversas embalagens do tipo "sacolê", comumente utilizadas para embalar drogas, e a importância de R\$ 269,00 em espécie, dinheiro angariado com a venda de drogas que os acusados promoviam no bairro, de forma associada. Ato contínuo, Davi efetuou

contato com DANIEL, que compareceu no local, isentou o irmão e informalmente admitiu a prática delitiva. Os réus foram notificados (fls. 146 e 148) e apresentaram Defesas Preliminares (fls. 156/157 e 161/162). Assim, por decisão proferida no dia 22 de junho de 2022, foi recebida a Denúncia (fls. 163/166). Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas e, ao final, os acusados foram interrogados, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação dos acusados nos termos da exordial, enquanto a Defesa Técnica, ao revés, pugnou pela absolvição dos réus, sustentando, em apertada síntese, insuficiência probatória. Folha de antecedentes a fls. 34/37, bem como Certidões a fls. 42/55 e 58/63. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Preliminarmente oportuno salientar que a operação levada a cabo pelos agentes públicos em comento atendeu aos requisitos legais, não violando preceito constitucional ou abrigado em Lei. Ora, os guardas civis municipais, no momento em que receberam denúncia anônima acerca dos réus, não estavam efetuando diligências para investigações preliminares, mas sim realizando patrulhamento rotineiro para prevenir e inibir ações criminosas contra o patrimônio público municipal, atribuição esta lhes conferida por lei ordinária (art. 5º, II, da Lei nº 13.022/2014), a qual regulamentou a competência atribuída em nossa Carta Magna a esta corporação (art. 144, § 8º, da CF). Faz-se mister ressaltar, outrossim, que os guardas civis municipais não extrapolaram suas funções. Deveras, se presente o estado de flagrância delitiva, a atuação de "qualquer pessoa do povo" seria legal, de acordo com a previsão legal insculpida no art. 301 do Código de Processo Penal. Por tal razão, não há óbices para a ação dos guardas civis municipais, os quais, por serem agentes de segurança, não devem se manter inertes diante de patente atividade criminosa. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, não é necessário resultado decorrente da ação ou omissão, bastando a simples conduta para a constituição do elemento material da figura típica penal, o que afasta a dúvida sobre o estado de flagrância delitiva do recorrente. 2. Dessa forma, à luz do art. 301 do CPP, "qualquer do povo" poderia ter efetuado sua prisão em flagrante, aí incluídos os agentes públicos da guarda municipal. 3. Afastada qualquer ilegalidade na custódia provisória decorrente de flagrante delito, afastado está o seu relaxamento. 4. Recurso a que se nega provimento. (STJ - RHC: 17645 SP 2005/0066036-6, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 06/09/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/09/2005 p. 408) (grifos aditados). Acrescente-se que até mesmo o legislador ordinário acolheu este entendimento, pois no art. 5º, inciso XIII, da Lei nº 13022/2014, atribuiu a Guarda Civil Municipal a competência de "garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas", consolidando o entendimento jurisprudencial acima exposto. In casu, o acusado Cauã foi surpreendido trazendo consigo drogas, legitimando sua prisão em flagrante e a atuação da Guarda Civil Municipal. E, consequentemente, sendo lícita a diligência dos agentes públicos. Já em relação a Daniel, este fora apontando por Cauã, o ingresso em sua residência fora autorizada por seu irmão

Davi, que inclusive confirmou a autorização nesta data em sua oitiva, e armazenava substância entorpecente em sua residência, ou seja, em evidente e indiscutível estado flagrancial. Superada a preliminar arguida, o pedido ministerial comporta parcial procedência, absolvendo-se os réus da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:" (grifos aditados). No entanto, para se que não se confunda o mero concurso de pessoas - de que trata o

art. 29 do Código Penal – com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro, denotando vínculo associativo e não mero concurso eventual. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes. (...)” (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013). Além disto, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...)” (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014). Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: “(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...)” (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103). Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, noto que, embora haja comprovação de que os acusados exerciam o tráfico de entorpecentes, inexistem provas suficientes de que praticavam ou pretendiam perpetrar a narcotraficância em caráter permanente. Isto porque não houve prévia investigação policial, onde fosse possível verificar que o tráfico não seria exercido pontualmente, tampouco foram localizados instrumentos de preparação ou anotações de contabilidade, revelando o caráter não episódico da traficância. Portanto, diante da ausência de provas em relação ao animus associativo entre o réu e o adolescente, imperiosa a absolvição deles no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), pelo auto de constatação preliminar (fls. 22/23), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 121/125) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente. Vejamos: O réu DANIEL, em depoimento policial (fls. 06), manteve-se em silêncio. Em juízo, negou os fatos. Estava na casa de sua mãe, para pedir desculpas por uma discussão no dia anterior. No correr do dia estava em frente a casa de sua mãe e passou uma pessoa e disse que havia polícia em sua casa. Quando chegou em sua casa, os policiais estavam saindo com seu irmão. Tinha 3 saquinhos de droga em sua casa, que eram para seu uso e tinha saquinho que iria começar a vender espetinho – kafta. Não tinha nenhum dinheiro. Não é nada de Cauã, não são amigos. Já conhecia os guardas que fizeram a abordagem, pois namorava uma menina e eles disseram para ela que iriam forjá-lo no tráfico, depois de uns dias foi abordado numa bicicletaria, ficaram com ele uma hora e meia para que ele assumisse o tráfico. Não tem filhos. Não usava droga perto do seu irmão. Foi preso em janeiro pois jogaram droga nele e o acusaram de tráfico. De outro lado, o acusado CAUÃ, em depoimento policial (fls. 10), afirmou que no momento que os guardas municipais o abordaram, somente localizaram o valor de R\$ 20,00. Não estava com entorpecentes, bem como negou a prática do tráfico de drogas. Em juízo, disse que havia comprado uma única porção de Aricanduva, os policiais o abordaram,

não tentou correr, e jogou a porção. Estava ainda com vinte reais em seu bolso. Entrou dentro da viatura e os policiais disseram que o levaria para sua casa, mas ele seguiu para casa de Daniel, ocorre que não conhece Daniel, nunca o viu, não citou seu nome ou sua casa. Quanto a denúncia anônima, toda audiência os guardas falam isso. Tinha comprado essa porção na viela. Quando era menor era muito conhecido, pois tinha envolvimento com droga, mas quando saiu da Fundação já parou com tudo. Sentia-se perseguido pelos policiais que paravam sua esposa e diziam que ele era envolvido com o tráfico e que iriam pegá-lo. Tinha até medo de sair na rua pois se sentia perseguido. Os guardas ouvidos nessa ocorrência sempre o perseguiam. Tem 18 anos, tem passagem pela vara da infância. Estava trabalhando. Tem uma filha. Analisando a autodefesa dos acusados - colhidas com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - resta evidente que ambos os réus negaram a autoria delitiva. Contudo, não apresentaram versão verossímil, tampouco elementos probatórios que de qualquer forma corroborassem a negativa de autoria. Mas, por outro lado, a prova dos autos revela cabalmente a prática do tráfico de drogas, tal como relatada na denúncia. Com efeito, o Guarda Civil Municipal Daniel da Silva Martino, em sede policial (fls. 02/03), declarou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, durante patrulhamento pelo Bairro Vila Angélica, foram abordados por um popular, dizendo que tinha um rapaz de nome Cauã, de bicicleta, que usava camisa verde de time e boné vermelho, estava indo buscar drogas na casa do Daniel, localizada na Rua Ismenia Maria dos Santos, 236, para vender para os viciados. Quando entraram na rua Isaltina Campos Vieira, avistaram o Cauã, o qual, ao avistar a viatura, dispensou algo na rua. Em seguida, foi abordado e, ao realizar busca pessoal, foi encontrado o valor de R\$ 20,00. Após, foram até o local onde ele tinha dispensado algo, sendo localizado três porções substância análoga a cocaína, tipo Aricanduva. Instado, CAUÃ confessou a mercancia de entorpecentes e disse que tinha acabado de pegar os entorpecentes em na casa do DANIEL. A equipe deslocou-se até a residência de DANIEL e, ao chegar, encontraram o irmão dele, o Davi. Informaram a ele sobre o acontecido e ele informou que residia no local, que desconhecia se existia drogas no local, permitindo a entrada dos guardas na residência. Foi localizada na lavanderia, dentro de um tanquinho, mais 13 porções de cocaína, tipo aricanduva, idênticas que estavam com CAUÃ, mais 9 porções de maconha e, no armário, mais R\$ 269,00 em espécie, dois rolos plásticos filme e vários sacolés. Davi presenciou os guardas municipais localizarem os entorpecentes. Após, contataram DANIEL, que foi até o local e disse que o irmão Davi não tinha nada haver com os entorpecentes, assumindo o tráfico e que o dinheiro localizado também é oriundo do mercancia de drogas. Em juízo, a testemunha disse que estavam em patrulhamento pela Vila Angelica quando um senhor os abordou e disse que Caua que estava de bicicleta e uma camiseta de time, pegava a droga na casa de Daniel e vendia o bar do gordo. Foram ao local em que estariam os réus, visualizaram Cauã que dispensou 03 porções do tipo Aricanduva. Caua disse que havia pegado a droga com Daniel. Foram até a casa de Daniel, lá estava o irmão dele, que autorizou a busca domiciliar. Na residência, num tanquinho desativado foram encontradas mais porções de cocaína e maconha. No armário foi encontrado dinheiro, sacolés e papel filme. Davi ligou para Daniel, Daniel foi até o local, admitiu a propriedade e eximiu qualquer participação de seu irmão. Cauã disse que tinha pegado a droga a pouco tempo. Convergingo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Eduardo Leopoldo Ambold, em sede policial (fls. 04), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a

palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Finalmente, a testemunha Davi dos Santos, em solo policial (fls. 05), afirmou que reside na mesma casa com o seu irmão DANIEL DOS SANTOS. Tem conhecimento que o seu irmão tem envolvimento com o tráfico de drogas, pois ouviu comentários que o seu irmão foi visto na "biqueira". Na data dos fatos, no momento que os guardas municipais chegaram na porta de sua casa, disse aos guardas que não tinha conhecimento se existia drogas dentro da casa, permitindo que os guardas municipais entrassem na sua residência. Ainda informou que acompanhou os guardas, presenciando o momento que eles localizaram os entorpecentes, dinheiro e os plásticos. Também presenciou o momento que o seu irmão DANIEL confessou que os entorpecentes localizados eram dele e que estava traficando. Em juízo, a testemunha que é irmão do réu foi ouvido sem compromisso. Disse que no dia dos fatos havia chegado do serviço e estava deitado em sua cama, quando se deparou com o pessoal da polícia, perguntou o motivo e eles disseram que era uma denúncia por tráfico e se podia averiguar a casa. Os policiais ingressaram no local, fizeram uma busca e encontraram uma porção de cocaína. Não sabia que havia droga no local. Já estava em sua casa há duas horas e não havia ninguém no local. Caua não estava em sua casa, não o conhecia e ele chegou com os policiais. No dia, quando saiu de sua casa o Daniel estava ali, mas não sabe dizer o horário que ele saiu, pois ele sai direto. Não tinha ciência do envolvimento de Daniel com o tráfico. Ficou assustado, nem imaginava. É verdade que seu irmão havia sido preso por tráfico em janeiro. Já chegou até a colocar o irmão dele para fora de casa por causa dos rumores de que ele estava envolvido com o tráfico. Conversou com seu irmão e ele prometeu que não iria se envolver e o deixou ficar em casa. Na sua casa foi encontrado entorpecente, um plástico e dinheiro. Nunca viu seu irmão fazendo uso de entorpecentes em casa. Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que os acusados traziam consigo e guardavam substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos agentes de segurança, os quais narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas com os acusados e o restante na casa de DANIEL; 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 121/125), o qual atestou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes; e 3) o depoimento de Davi, confirmando ter presenciado a apreensão de drogas na casa em que vive com DANIEL. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda "a varejo" de entorpecentes; 3) a não apreensão de instrumentos utilizados para o consumo da droga; 4) o comportamento suspeito do acusado CAUÃ, consistente em, ao notar a presença policial, dispensar drogas; 5) a informação dos policiais, de que, informalmente, os acusados confessaram a prática do tráfico de drogas; 6) a exata

correspondência entre as circunstâncias geográficas e nominal dos traficantes delatados com as dos acusados; e 7) o depoimento de DAVI, confirmando que DANIEL tem envolvimento com o tráfico e que, informalmente, esse confessou a prática delitiva apurada nos autos. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 121/125) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – guardar e manter em depósito –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo

legal retro mencionado. Certo, portanto, que os réus perpetraram o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhes imposta. Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias judiciais são favoráveis aos réus. De fato, observo que os apontamentos criminais retratados a fls. 42 e 46 se referem a ações penais em curso e, a despeito de entendimento pessoal diverso dessa Magistrada, observo que a jurisprudência se consolidou no sentido da imprestabilidade desses registros delitivos como maus antecedentes ou para a valoração negativa em primeira fase (Súmula nº 444 do STJ). Aliás, assim também tem se posicionado a jurisprudência do E. TJSP, apontado que ações penais em curso, ainda que condenações provisórias: “embora tal circunstância denote a personalidade desregrada do acusado, não se presta a majorar a sanção inicial, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.” (TJSP; Apelação Criminal 1502727-43.2020.8.26.0037; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021). Desse modo fixo a pena-base dos acusados no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, ante à minguagem de outras causas modificadoras da pena a incidir. Deve-se frisar que, a despeito dos acusados possuírem menos de 21 anos quando dos fatos, deixei de aplicar a atenuante de menoridade relativa, já que a pena-base fora fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). E mais, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que os acusados se valeram das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, tratam-se de réus que estão sendo processados em outros feitos pelo mesmo delito que se apura nos autos (fls. 42 e 46), o que é elemento caracterizador de dedicação a atividades criminosas, restando inviabilizada a concessão da benesse em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: “É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.” (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33, § 3º, c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que os réus iniciem o cumprimento da pena no regime fechado, considerando a personalidade dos acusados (fls. 42 e 46), bem como pelo histórico infracional de ambos (fls. 44/45 e 58), além da gravidade concreta do delito, refletida pela quantidade e diversidade da droga que seria traficada. A tão só quantidade de pena aplicada obsta a substituição da pena privativa de

liberdade por restritivas de direitos e inviabiliza a concessão do sursis. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE Procedente a pretensão punitiva para: 1) condenar os réus DANIEL DOS SANTOS e CAUÃ VINICIUS BARROS DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos, como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; e 2) absolver os acusados da imputação de prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória do acusado. E mais, tratam-se de réus que desde sua adolescência envolvem-se com atividades ilícitas (fls. 44/45 e 58) e que estão sendo processados também pela traficância em outro feito (fls. 42 e 46), de modo a revelar que, acaso soltos, tornarão a delinquir, razão pela qual a manutenção da prisão cautelar de ambos é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento, bem como arquivem-se os autos. Isentos os acusados do pagamento das custas processuais, concedendo-lhes os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intimem-se os réus para que efetuem o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do bem apreendido (R\$ 520,00 - fls. 86), pois comprovada sua proveniência criminosa, em favor da união, apropriados ao Funad (§1º do referido art. 63). Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 289,00 em dinheiro - fls. 128) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP". Pelos Defensores dos réus e pelos réus foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo os recursos interpostos pelos réus, saindo os Defensores, desde já, intimados a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeçam-se as competentes certidões de honorários (fls. 149/150). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA